

1501115-49.2022.8.26.0571

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Alfredo Gehring Cardoso Falchi Fonseca

Comarca: Itapetininga

Foro: Foro de Itapetininga

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/11/2022

... como já dito, a associação para o tráfico é absolutamente incompatível com a minorante do tráfico "privilegiado". O regime inicial de cumprimento de pena deverá ser o fechado tendo em vista a variedade e grande quantidade de drogas apreendidas, bem como a associação para o tráfico. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapetininga

Foro de Itapetininga

2ª Vara Criminal

Avenida Peixoto Gomide, centro, Itapetininga - SP - cep 18200-160

TERMO DE AUDIÊNCIA - VIDEOCONFERÊNCIA

Processo nº:

1501115-49.2022.8.26.0571 - Controle 2022/001314

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JONATHAN RODRIGUES DE OLIVEIRA e outro

Data da Audiência:

01/11/2022

Iniciados os trabalhos por videoconferência, com concordância das partes (inclusive dos réus), verificou-se a presença do Exmo. Sr. Dr. Alfredo Gehring Cardoso Falchi Fonseca, MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Criminal de Itapetininga, dos representantes do Ministério Público e da Defensoria Pública, e dos Acusados Jonathan Rodrigues de Oliveira e Beatriz Aparecida Mendes. Na "sala virtual" permaneceram exclusivamente o Defensor e seu representado para contato prévio. Antes de serem inquiridas as testemunhas foram devidamente advertidas acerca da incomunicabilidade.

Foram ouvidas as testemunhas Marcos Rogerio de Almeida e Antonio César Alapone de Oliveira arroladas pelas partes. Em seguida os réus foram interrogados. Os depoimentos foram registrados pelo sistema Microsoft Teams. Pelas partes foi dito que não tinham diligências a requerer. Pelo(a) MM(a). Juiz(a) foi dito que: Não havendo mais provas a serem colhidas, declaro encerrada a instrução, determino as partes que passem aos debates. Dada a palavra ao Dr. Promotor de Justiça, foi dito: MM. Juiz, Os réus foram denunciados e estão sendo processados como incursos no artigo 33, "caput", e artigo 35, "caput", ambos da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 69, "caput", do Código Penal, pois, em data anterior a 19 de agosto de 2022, em horário e local incertos, nesta cidade e comarca de Itapetininga, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente, o crime de tráfico ilícito de drogas, tipificado no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06. Além disso, no dia 19 de agosto de 2022, por volta da meia noite e quinze, na Rua Bem Aventurado José Maria Escrivã, nº 14, Bloco 14, Vila Sônia, nesta cidade e comarca de Itapetininga, guardavam, tinham em depósito e traziam consigo, para entrega a consumo e fornecimento, ainda que gratuito: a) 221 (duzentas e vinte e uma) porções de "cocaína", com peso líquido de 18,54g (dezoito gramas e cinquenta e quatro

centigramas); b) 31(trinta e uma) porções de “maconha”, com peso líquido de 136,70g (cento e trinta e seis gramas e setenta centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Os réus foram notificados (fls. 127 e 134) e apresentaram defesas prévias (fls. 131/132 e 138/139). A denúncia foi recebida em 06/10/2022 (fls. 140/141) e os acusados foram citados pessoalmente (fls. 109). Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes. Os réus foram interrogados. É este o breve relatório. Penso que a ação deve ser julgada procedente. A materialidade do delito restou comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 16/17), de constatação (fls. 20/21) e pelo laudo do exame químico-toxicológico (fls. 102/105). A autoria também foi devidamente demonstrada. Vejamos. Em solo policial, o réu JONATHAN negou a prática dos fatos. Disse que trazia consigo apenas a quantia de R\$ 4,00 em dinheiro e um fone de ouvido. Não sabe se a corré tinha algo de ilícito. Falou que não foram até o abrigo de gás (fls. 05). No mesmo sentido o interrogatório de BEATRIZ, que negou o narcotráfico. Falou que ninguém correu quando a polícia chegou (fls. 06). Interrogados em Juízo, JONATHAN afirmou que havia acabado de chegar do seu trabalho. A polícia aproximou-se. O verdadeiro traficante que atuava no local fugiu. Ficou no local esperando a abordagem, tranquilo. Não tinha droga nenhuma consigo. Enfim, defendeu um panorama de flagrante “forjado”. BEATRIZ também negou a prática do crime. Segundo ela, estava no local bebendo e conversando. Os policiais acharam a droga e, injustamente, acabou presa. As porções de “maconha” e “cocaína” não lhe pertenciam. A prova oral é suficientemente segura ao incriminá-los. Com efeito, diz a denúncia que, antes do dia 19 de agosto de 2022, os acusados, que são conhecidos e moradores da Vila Palmeira, associaram-se para a prática reiterada do tráfico de drogas. Ficou combinado entre ambos que, após receberem os entorpecentes dos fornecedores, praticariam o crime de tráfico nos chamados “Predinhos da Vila Sônia”. Foi combinado, também, que se revezariam no atendimento aos usuários, conforme a demanda exigisse. No dia 19 de agosto de 2022, policiais militares resolveram, de longe, fazer campana no local, tendo em vista tratar-se de um dos pontos mais conhecidos de tráfico da cidade. Assim, os militares perceberam que os acusados estavam sentados próximos à escadaria de entrada dos prédios. Notaram que ambos, alternadamente, dirigiam-se à frente do prédio e vendiam as porções solicitadas pelos usuários, recebendo o respectivo preço. Na oportunidade, os policiais avistaram que os acusados se deslocavam até um abrigo de gás, ponto em que se abaixavam e se abasteciam de mais porções, retornando à escadaria para o atendimento dos adquirentes. Em face dessa dinâmica, os militares decidiram abordá-los, permanecendo nos fundos, enquanto o motorista da viatura veio pela frente dos prédios. Quando os acusados perceberam a aproximação da viatura, tentaram correr, mas se depararam os outros policiais ao fundo do local, momento em que foram detidos. Realizadas as suas buscas pessoais, em poder de JONATHAN, numa pochete que trazia na cintura, foram encontrados três pinos de cocaína e duas porções de maconha, além do valor de R\$ 14,00 em espécie. Com BEATRIZ, foram localizados, no bolso de sua blusa, três pinos de cocaína, a quantia de R\$ 20,00 em dinheiro e um aparelho celular, marca Samsung. Na sequência, foram ao local onde eles guardavam as porções, ou seja, ao abrigo de gás, local em que localizaram as demais porções, todas idênticas àquelas que os denunciados traziam consigo. Em razão dos fatos, ambos foram presos em flagrante, sendo conduzidos a solo policial para as demais providências. Pois bem. Agora, o policial Marcos Rogério afirmou que estava em patrulhamento com seus colegas, quando resolveram observar os fundos dos “prédios”, conhecido como ponto de venda de drogas. Durante o período de observação, puderam observar que a dupla ficava sentada nas escadas do imóvel, revezando-se no atendimento à clientela de usuários. Eventualmente, quando a droga acabava, dirigiam-se até um abrigo de gás e recompunham o estoque. Em dado instante, houve a deliberação pela abordagem. Ambos traziam consigo algumas porções de drogas e dinheiro. Por fim, foram até o abrigo do gás e lá encontraram mais 215 pinos de “cocaína” e 29 porções de “maconha”. Ambos negaram a prática do crime. O policial Antônio César fez coro às palavras do seu colega. Pontuou que a dupla se revezava no atendimento aos usuários e que armazenava as drogas que vendiam em um abrigo destinado à proteção de botijões de gás. Conforme se nota, é evidente que os

acusados se associaram para a prática reiterada do crime de tráfico de drogas, bem como executavam o que tinham combinado até a abordagem policial acima narrada. A dinâmica dos fatos, a variedade e quantidade de drogas e a apreensão de quantia em dinheiro demonstram que o acusado possuía todas as porções para fins de tráfico. Assim, a prova é firme ao incriminar os acusados. Registre-se que nada está a indicar que as testemunhas estejam a prejudicar inocentes ou a fantasiar sobre as circunstâncias do crime. Suas palavras foram firmes, harmônicas e coerentes, de modo que merecem todo crédito. Dessa forma, os fatos narrados na inicial acusatória foram devidamente comprovados. Impõe-se, pois, a integral procedência da ação. Passemos, então, à análise da pena. Observo que o réu JONATHAN ostenta maus antecedentes e é reincidente (fls. 56/62 e 67/0). Assim, na primeira fase, a pena-base deverá ser fixada acima do mínimo legal. Já na segunda, a pena deverá ser agravada, ante a recidiva. Pelos mesmos motivos, incabível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06. Tendo em vista os maus antecedentes e a reincidência. Ademais a associação para o tráfico é absolutamente incompatível com a minorante em comento. Pelos mesmos motivos, o regime prisional deverá ser o inicial fechado e se mostra impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. BEATRIZ, por sua vez, não ostenta maus antecedentes e é primária (fls. 63/66). Na terceira fase, impossível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, pois, como já dito, a associação para o tráfico é absolutamente incompatível com a minorante do tráfico "privilegiado". O regime inicial de cumprimento de pena deverá ser o fechado tendo em vista a variedade e grande quantidade de drogas apreendidas, bem como a associação para o tráfico. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Ante o exposto, requer e espera o Ministério Público a procedência da ação penal, com a condenação dos réus nos exatos termos da denúncia, com decretação do perdimento dos valores. Dada a palavra ao Dr. Defensor, foi dito: MM. Juiz: Os acusados foram denunciados e estão sendo processados como incursos no artigo 33 e no artigo 35 da Lei nº 11.343/06. Ocorre que a pretensão persecutória não merece prosperar, visto que as provas levadas aos autos não autorizam a prolação de um édito desfavorável aos acusados. I- DO DELITO PREVISTO NO ART. 33. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. Como se sabe, a Constituição Federal garante a presunção de inocência, de tal sorte que se faz mister um conjunto probatório robusto e harmônico para que se autorize a prolação de um édito condenatório. Não é, todavia, o que ocorre na hipótese dos autos. Isso porque as provas produzidas pela acusação restringem-se, apenas, a palavra dos policiais. A testemunha policial Marcos narrou que, em patrulhamento pelo bairro Vila Sônia, resolveram fazer uma observação pelos fundos dos prédios que é local conhecido como ponta de drogas. Ficaram nos fundos do prédio por cerca de 20 minutos e ali viram a movimentação de Jonathan e Beatriz. Ambos ficaram sentados próximos a escada, iam até a frente do prédio e faziam entrega para alguém que chegava. Também iam até uma casinha de gás e pegavam algo. Depois desse tempo de observação, solicitaram ao motorista da viatura que viesse à frente, para que os réus saíssem do local pelos fundos. Assim, ambos vieram na direção dos policiais dos fundos e foram abordados. Em revista, localizaram drogas e dinheiro e com ambos. Depois, foram até a casinha de gás e localizaram mais entorpecentes, idênticos aos localizados com os réus. Não havia denúncia em específico envolvendo o nome

dos réus, mas foram até o local por ser conhecido como ponto de tráfico de drogas. Nunca abordou os réus juntos em data anterior, mas já conhecia os dois. Não abordaram nenhuma das pessoas que teriam recebido entorpecentes. A testemunha Alapone deu depoimento semelhante ao colega de farda. O réu, interrogado sob o crivo do contraditório, negou os fatos. Disse que estava nas escadarias com sua esposa, Beatriz e a companheira de Beatriz. O traficante do local saiu correndo quando a polícia apareceu, mas permaneceu ali, porque não devia nada. Já tinha se afastado das drogas há tempos e trabalhava, não tendo motivos para praticar o crime. A ré Beatriz, também sob o crivo do contraditório, negou os fatos. Disse que estava nas escadarias conversando com Jonathan, quando a polícia apareceu o traficante saiu correndo. Negou que traficasse. Não há absolutamente nada que

indique a prática delitativa por parte dos acusados, a não ser a suposta campana realizada pelos policiais, a qual sequer foi filmada e na qual os supostos usuários não foram identificados e ouvidos. Em poder dos réus teriam sido localizados pequena quantidade de entorpecente. Nenhum apetrecho foi localizado com eles e, apesar de todo o comércio ilícito que teriam realizado no período de 20 minutos, em poder de Beatriz foi localizada apenas a quantia de R\$ 20,00 e com Jonathan, R\$ 14,00. Ora, se o comércio durou todo esse tempo mencionado pelos policiais, teriam localizado maior quantidade de dinheiro com os acusados. Assim, a prova é fraca com relação a prática delitativa. Diante disso, é o caso de absolvição dos réus nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

III- DO DELITO PREVISTO NO ART. 35 DA LEI Nº 11.343/06. Da absolvição por falta de provas. Ausência de provas de permanência e estabilidade. O delito previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06 não restou minimamente configurado no caso. Não há, nos autos, qualquer indício no sentido de que os réus teriam se associado para o cometimento do tráfico de drogas. A acusação não foi precedida de investigações que comprovassem o elo subjetivo entre eles e, apesar da apreensão de celular no dia do ocorrido (fls. 16-17), ele sequer foi periciado. O mero fato de serem conhecidos um do outro não indica serem eles associados, visto que, conforme já exposto, a prova da associação deve ser precedida de sérias investigações (e não de mera presunção). De outra parte, posto que se considere que os réus teriam, em unidade de desígnios, cometido o tráfico, não há nos autos qualquer prova ou indício de que cometessem a empreitada criminosa de forma habitual, sendo que é inerente ao tipo (art. 35 da Lei de Drogas) tal associação, não bastando o simples “ajuntamento eventual”. Ou seja, associar-se significa unir-se de maneira estável com a finalidade de praticar diversos crimes. A característica da associação é a permanência e a estabilidade do vínculo. Há a necessidade de um animus associativo, isto é, um ajuste prévio no sentido da formação de um vínculo associativo de fato, uma verdadeira *societas sceleris*, em que a vontade de associar seja separada da vontade necessária à prática do crime visado. O STF decide em consonância com o sobredito, vejamos: “A associação para o tráfico de entorpecentes, como tipificada no art. 14 da Lei de Entorpecentes, dispensa o elemento mais característica das figuras penais de associação para delinquir, qual seja, a predisposição da *societas sceleris* à prática de um número indeterminado de crimes: para não confundir-se com o mero concurso de agentes, a melhor interpretação reclama á sua incidência o ajuste prévio e um mínimo de organização, seja embora na preparação e no cometimento de um só delito de tráfico ilícito de drogas, hipótese que a sentença julgou provada.” (STF, RHC 75236/AM, 1ª Turma, Rel. Sepúlveda Pertence, DJU 01.08.1997). No que toca ao delito de associação, a conduta expressa no artigo exige permanência, o que definitivamente não houve no caso em tela. Em harmonia com esse entendimento, confira-se o posicionamento judicioso dos respeitados doutrinadores Guilherme Octaviano Diniz Junqueira e Paulo Henrique Aranda Fuller: “O mero planejamento para uma eventual conduta de tráfico em conjunto fica evidentemente absorvido pelo próprio crime de tráfico, que exaure o potencial lesivo do planejamento, sem merecer relevância penal autônoma. Como não é possível crime sem lesão ou risco ao bem jurídico, a única interpretação viável e constitucional do artigo é que, para a tipificação da conduta, persiste sendo necessário a finalidade e permanência, como no crime de quadrilha do Código Penal, diferenciando-se daquela figura pelo elemento subjetivo (não basta querer praticar qualquer crime, mas apenas os previstos nos arts. 33, caput e § 1º, 34 e 36 da Lei de Drogas) e pelo número de agentes (para o Código Penal, um mínimo de quatro, enquanto na Lei de Drogas são suficientes dois)”. Diante do exposto, não tendo sido comprovada a associação estável e em virtude do respeito ao princípio *in dubio pro reo*, é imperiosa a absolvição dos acusados no que tange ao crime previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06.

III - COM RELAÇÃO À BEATRIZ. DA APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06. Requisitos legais preenchidos. Na hipótese vertente, encontram-se presentes todos os requisitos para a sua incidência, vez que a acusada é primária e tem bons antecedentes. Ademais, não há prova de que ela participe de organização criminosa ou que se dedique à prática de atividades ilícitas, o que não pode ser presumido. Neste ponto, cumpre ressaltar que, para que ocorra “dedicação às

atividades criminosas”, faz-se necessário que o agente pratique não um ou dois crimes, mas diversos atos ilícitos periodicamente, que faça de sua atividade cotidiana o cometimento de crimes, o que, no caso, não se deu, à vista da primariedade da denunciada. Finalmente, cabe observar que, consoante entendimento jurisprudencial pacífico, a quantidade de entorpecentes apreendida não basta, por si só, para afastar a incidência do redutor, se presentes seus requisitos legais. Na mesma linha, é o entendimento doutrinário, como bem aponta Luiz Flávio Gomes, verbis: “No delito de tráfico (art. 33, caput) e nas formas equiparadas (§ 1º), as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário (não reincidente), de bons antecedentes e não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa (traficante, agindo de modo individual e ocasional). Os requisitos são subjetivos e cumulativos, isto é, faltando um deles, inviável a benesse legal. A simples leitura do parágrafo pode induzir o intérprete a imaginar que o benefício está na órbita discricionária do juiz. Contudo, parece-nos que, preenchidos os requisitos, o magistrado não só pode como deve reduzir a pena, ficando sua discricionariedade (motivada) limitada à fração minorante (esta orientada pela quantidade e/ou espécie de droga apreendida”. (Lei de Drogas Comentada, 5ª edição, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2013, p. 178 – grifado). Assim, plenamente identificados os requisitos legais, deve incidir a hipótese de redução estampada no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

IV- TESES SUBSIDIÁRIAS. Em caso de condenação, na primeira fase da dosimetria das reprimendas, cabe ressaltar que a pena-base deve ser fixada no patamar mínimo legal, eis que a culpabilidade da ação dos acusados não extrapolam aquela inerente ao respectivo tipo penal, não tendo havido, ainda, maiores consequências da prática delitiva. Finalmente, quanto ao regime inicial de cumprimento das penas, cabe ressaltar, outrossim, que a gravidade do crime, por si só, não pode ser fundamento para a imposição de regime mais rigoroso, consoante entendimento já sumulado pelo Supremo Tribunal Federal (Súmula 718). Em relação a Beatriz, requer que seja fixado regime inicial aberto de cumprimento da pena, nos termos do art. 33 do Código Penal, substituindo-se a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, já que presentes os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal. Em relação ao réu Jonathan, requer-se a fixação do semiaberto, especialmente diante do fato de que as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis. Pugna-se, por fim, com fundamento no art. 8º, item 2, ‘h’, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos – Pacto de San José da Costa Rica, pela concessão do direito de recorrerem em liberdade. Na sequência, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte sentença: Vistos. JONATHAN RODRIGUES DE OLIVEIRA e BEATRIZ APARECIDA MENDES, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no art. 33, “caput”, e no art. 35, “caput”, da Lei n. 11.343/2006, na forma do art. 69, do Código Penal, porque, em data anterior ao dia 19 de agosto de 2022, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente, o crime de tráfico ilícito de drogas. Em 19 de agosto de 2021, por volta da meia-noite e quinze, na Rua Bem Aventurado José Maria Escrivã, n. 14, Bloco 14, Vila Sônia, nesta Cidade e Comarca, os Réus, enquanto colocavam em prática as atividades para as quais a associação delituosa fora constituída, guardavam, mantinham em depósito e traziam consigo, para fins de tráfico, duzentas e vinte e uma porções de “cocaína”, com peso de 18,54 gramas e trinta, e uma porções de “maconha”, com peso de 136,70 gramas, ambas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. O Acusado Jonathan Rodrigues foi notificado, fls. 127, e apresentou defesa preliminar, fls. 131/132; igualmente a Ré Beatriz Aparecida, fls. 134, apresentou defesa, fls. 138/139. A denúncia foi recebida, fls. 140/141 e os Réus, citados, fls. 159 – Jonathan Rodrigues e fls. 164 – Beatriz Aparecida. Durante a instrução, foi colhido o depoimento das testemunhas arroladas pelas partes, seguindo-se o interrogatório dos Réus (gravação por videoconferência). Em alegações finais

o Dr. Promotor de Justiça pediu a condenação nos exatos termos da inicial; por seu turno, a Dra. Defensora Pública insistiu na absolvição e na aplicação de benefícios. É o relatório. I – FUNDAMENTO. Às fls. 16/17 foi juntado o Auto de Exibição e Apreensão no qual consta: um telefone celular, marca Samsung, cor prateado; 221 porções de cocaína, com peso de 135,07 e 31 porções de maconha, com

peso de 152,81 gramas. Às fls. 102/105 foi juntado o Laudo Pericial de Exame Definitivo em Substância Entorpecente n. 264.589/2022, no qual consignou: "Dos resultados. Item I - Utilizando-se metodologias adequadas para análise do referido material, foi detectada a presença da substância Tetrahydrocannabinol (THC), constante na lista F2: Lista de Substâncias Psicotrópicas - Lista das Substâncias de uso Proscrito no Brasil da portaria SVS/MS 344/1998 e atualizações posteriores. Item II - Utilizando-se metodologias adequadas para análise do referido material, foi detectada a presença da substância Cocaína, constante na lista F1: Lista das Substâncias Entorpecentes - Lista das Substâncias de uso Proscrito no Brasil da portaria SVS/MS 344/1998 e atualizações posteriores". Marcos Rogério de Almeida e Antônio César Alapone de Oliveira, policiais militares, testemunhas, disseram que estavam em patrulhamento e, cientes do elevado índice de tráfico de entorpecentes naquela localidade, fizeram observações acerca da conduta dos réus; postaram-se atrás do bloco 14 e viram os acusados, os quais estavam sentados atrás da escadaria de entrada e revezavam-se no atendimento de usuários, e também se deslocavam até o abrigo do gás e pegavam algo; assim, enquanto os policiais permaneceram nos fundos, o motorista foi com a viatura até a frente, oportunidade em que os réus fugiram e foram abordados, e, com o Réu Jonathan, os policiais encontraram três pinos de "cocaína" e duas porções de "maconha" e R\$ 14,00, e, com a Ré Beatriz, os policiais localizaram três pinos de "cocaína" e R\$ 20,00 em dinheiro; na sequência os policiais foram ao local de armazenamento e lá apreenderam 215 pinos de "cocaína" e 29 porções de "maconha". Jonathan Rodrigues de Oliveira, Réu, ao ser interrogado, disse que tinha chegado do trabalho e ficou nas escadarias juntamente com a esposa; os policiais vieram, o traficante correu para os fundos, mas não foi preso; na sequência o Réu foi abordado; não tinha entorpecentes. Beatriz Aparecida Mendes, Ré, ao ser interrogada, disse que estava nas escadarias e os policiais vieram; foram abordados, mas não havia drogas consigo. Confrontando-se a prova coligida, de acordo com os policiais, os acusados foram vistos revezando-se no atendimento de usuários, a quem entravam algo e de quem recebiam algo, além de periodicamente irem ao abrigo do gás, onde havia porções de "maconha" e de "cocaína", circunstância posteriormente descoberta. Feita a abordagem os policiais encontraram, com o Réu Jonathan, três pinos de "cocaína", duas porções de "maconha" e R\$ 14,00, e, com a Ré Beatriz, os policiais localizaram três pinos de "cocaína" e R\$ 20,00 em dinheiro; na sequência os policiais foram ao local de armazenamento e lá apreenderam 215 pinos de "cocaína" e 29 porções de "maconha". Destarte, é óbvia não somente a relação de propriedade das drogas em relação aos réus, como a finalidade mercantil, já que foram vistos no atendimento de usuários e, ademais, a diversidade e a quantidade de drogas, bem como o número de porções, são incompatíveis com o uso pessoal pelos acusados. Não há razão para desprezar a prova acusatória porque as testemunhas relataram detalhes a respeito da abordagem, localização e apreensão do entorpecente. As testemunhas não têm motivos para incriminar um inocente. Não se conhece razão plausível para que as testemunhas arquitetassem diabólico plano visando incriminar estes Réus, apontando-os como autores dessa espécie de crime. Tudo indica que as testemunhas agiram com lisura e, por certo, não se poderia desacreditar o relato de cada qual, uma vez que apenas tais pessoas é que presenciaram e participaram da diligência de localização da droga, não se podendo entender como suspeitos. Portanto, de acordo com o examinado, está comprovado que os Réus traziam consigo, guardavam e mantinham em depósito substâncias entorpecentes, condutas estas que configuram a consumação do delito de tráfico de entorpecente, pois, para a configuração do crime previsto no "caput", do art. 33, da Lei nº 11.343/06, de ação múltipla ou conteúdo variado, basta que o agente realize qualquer das condutas descritas no tipo penal que, "in casu", foi a de trazer consigo, guardar e manter em depósito, ilegalmente, substância entorpecente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Evidente o dolo direto dos agentes, isto é, a vontade livre e consciente de praticarem a conduta descrita no tipo do art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06. Do delito de Associação ao tráfico de drogas. Analisando-se o conjunto probatório, conclui-se no sentido de que falta a presença de elementos de convicção confirmando a existência de vínculo associativo e estável entre os Réus. Apenas

houve a abordagem e a localização do entorpecente. Não houve investigações para elucidar eventual estabilidade da eventual associação. Como é cediço, para a condenação, exige-se certeza absoluta da responsabilidade daquele apontado como autor do delito e, para tanto, não provas contraditórias e pouco esclarecedoras a respeito da responsabilidade dos agentes. Essas circunstâncias fazem surgir ao Juiz dúvida invencível que, no processo penal, resolve-se em favor da defesa, por aplicação do princípio *in dubio reo*, e impõe o reconhecimento do *non liquet*, com a absolvição dos Réus no que diz respeito ao delito estatuído pelo art. 35, da Lei 11.343/06, com fulcro no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal. II – DA DOSIMETRIA DA PENA. (Art. 59, inc. II, do Código Penal). Fixada a responsabilidade dos acusados, passo à dosimetria das penas. JONATHAN RODRIGUES DE OLIVEIRA: - Art. 59, “caput”, do Código Penal: As circunstâncias judiciais são favoráveis, assim fixo a pena – base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias – multa, no piso. - Art. 61 e Art. 65, ambos do Código Penal: O Réu é reincidente múltiplo, fls. 67 (Proc. 543-46.2017) e fls. 68/69 (Proc. 5661-41.2014), razão pela qual elevo 1/5 à pena e fixo-a em 06 (seis) anos de reclusão e de 600 (seiscentos) dias – multa, no piso. ART. 68: Quanto à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006, é ela reservada ao “pequeno traficante”, de bons antecedentes, que não se dedica a atividades criminosas, nem integra organização criminosa. O Réu é reincidente múltiplo, portanto deixo de aplicar a causa de diminuição de pena, pois não se enquadra nos requisitos legais, uma vez que se dedica a atividades criminosas. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA – ART. 59, INC. III, DO CÓDIGO PENAL: Em razão da pena aplicada e da reincidência múltipla, o Réu deverá cumprir a pena no regime inicial fechado. Não há falar em detração tendo em vista as mencionadas circunstâncias. - Art. 59, inc. IV, c/c Art. 44, do Código Penal: Em razão da pena aplicada e da reincidência múltipla, o Réu não faz jus à substituição. - Art. 77, do Código Penal: Em razão da pena aplicada e da reincidência múltipla, o Réu não faz jus ao *sursis*. BEATRIZ APARECIDA MENDES: - Art. 59, “caput”, do Código Penal: Considero boas as circunstâncias judiciais, razão pela qual fixo a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias – multa, no piso. Art. 61 e art. 65, do CP: A Ré é menor de 21 anos, logo faz jus à atenuante. Todavia, na segunda etapa, a atenuante não tem o condão de minorar a reprimenda aquém do piso legal. Esse é o entendimento consubstanciado na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. Art. 68, do CP: Considerando-se a quantidade de entorpecentes, aplico a causa de diminuição de pena e a reduzo em 2/3. Fixo-a em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e de 166 (cento e sessenta e seis) dias – multa, no piso, que torno definitiva. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA – ART. 59, INC. III, DO CÓDIGO PENAL: O plenário do E. Supremo Tribunal Federal, em 1.º/09/2010, ao julgar o Habeas Corpus n.º 97.256/RS, reconheceu incidentalmente a inconstitucionalidade da parte final do artigo 44 da Lei n.º 11.343/06, bem como da análoga expressão contida no § 4.º do artigo 33 daquela mesma norma, passando a admitir que, nos crimes de tráfico de menor potencial ofensivo, o juiz sentenciante, numa “empírica ponderação de circunstâncias objetivas com protagonizações subjetivas do fato-tipo”, pode substituir a pena privativa de liberdade abstratamente cominada para o crime por penas restritivas de direitos. Na sequência o Senado Federal, através da Resolução n.º 5/12, publicada em 16/02/2012, suspendeu a execução da expressão “vedada a conversão em penas restritivas de direitos”, contida no último dispositivo legal acima mencionado. Noutra decisão mais recente, proferida nos autos do Habeas Corpus n.º 111.840/ES, o Supremo Tribunal Federal, reconhecendo ofensa à garantia constitucional da individualização da pena, fez a declaração incidental de inconstitucionalidade do § 1.º do artigo 2.º da Lei n.º 8.072/90, afastando a obrigatoriedade de fixação do regime fechado para início do cumprimento de pena decorrente da condenação por crime hediondo ou equiparado (j. 27/06/2012, rel. Min. Dias Toffoli). O Superior Tribunal de Justiça já vem se alinhando àqueles entendimentos, conforme se viu no julgamento do Habeas Corpus 176.919/DF, onde foi concedida a ordem para estabelecer o regime aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade e para substituir esta por prestação de serviços à

comunidade e limitação de fim de semana

(rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 04/11/2010, Dje 13/12/2010). Na hipótese, o réu havia sido condenado por tráfico de drogas, lhe sendo imposta uma sanção de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, tendo sido reconhecida a sua primariedade e a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Portanto, em razão da pena aplicada e das circunstâncias judiciais, a Ré poderá cumprir a pena no regime aberto, já considerada a detração. - Art. 59, inc. IV, c/c Art. 44, do Código Penal: Preenchidos os requisitos previstos nos incs. I, II e III, do art. 44, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos, a prestação de serviços à comunidade, e limitação de fim de semana. III - DECIDO. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia e o faço para condenar JONATHAN RODRIGUES DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e de 600 (seiscentos) dias - multa, no piso, sendo o valor unitário de cada dia-multa de 1/30 do salário - mínimo vigente ao tempo da conduta, por incidir no art. 33, "caput", da Lei nº. 11.343/2006; e BEATRIZ APARECIDA MENDES, qualificada nos autos, a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial aberto, e de 166 (cento e sessenta e seis) dias - multa, no piso, sendo o valor unitário de cada dia-multa de 1/30 do salário - mínimo vigente ao tempo da conduta; por incidirem no art. 33, "caput", da Lei nº. 11.343/2006. Substituo a pena privativa de liberdade da Ré Beatriz pela pena restritiva de direitos, a prestação de serviços à comunidade, pelo tempo da pena privativa de liberdade, e limitação de fim de semana. Absolvo-os, com fundamento no art. 386, inc. VII, do CPP, da acusação de incidir na conduta prevista no art. 35, "caput", da Lei nº 11.343/2006. Deixo de condená-los nas custas. A Ré Beatriz respondeu ao processo em liberdade e poderá nessa condição interpor eventual recurso. O Réu Jonathan respondeu preso ao processo e, subsistentes as razões da custódia cautelar, deverá nessa condição interpor eventual recurso. Trata-se de Réu reincidente múltiplo. Ora, seu comportamento demonstra claramente a necessidade de ser mantida a custódia cautelar, na medida em que age com descaso com a Justiça, vez que, processado e condenado anteriormente, apesar de ter experimentado os rigores do cárcere, não mudou sua conduta, o que torna a medida excepcional necessária para a garantia da ordem pública, a fim de evitar reiteração criminosa. Destarte, as medidas diversas da prisão não se apresentam suficientes na hipótese, ante o descumprimento das ordens judiciais e a constante inobservância da legislação penal, o que torna a medida excepcional necessária para a garantia da ordem pública, a fim de evitar reiteração criminosa. Recomende-se no presídio em que se encontrar recolhido. Sentença publicada em audiência. Cumpra-se. A presente audiência foi realizada excepcionalmente por meio virtual, diante da Pandemia do COVID-19. O Termo de Audiência ficará disponível no sistema SAJ, ficando os presentes intimados do prazo de 5 (cinco) dias para interposição do recurso da sentença, dispensada a assinatura das partes, por se tratar de processo digital - sistema SAJ (Artigo 1.269 das NSCGJ). Nada Mais. Itapetininga, 01 de novembro de 2022. Eu, (RAFAEL MORAIS DA SILVA), Escrevente Técnico Judiciário digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA